

1502705-64.2021.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... praticado os crimes. Foi condenado por tráfico, não estava morando mais na Casa Grande e ficou longe do réu Brian (amigo de infância). Não lembra onde estava na data dos crimes. Disse que não conhece o réu Mateus. Trabalhava revendendo máquinas no Facebook. Tem condenação por tráfico. O policial Cleber e outros fazem acertos nas biqueiras. Conhece de vista o Escrivão. Na rede ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1502705-64.2021.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502705-64.2021.8.26.0161 Controle nº 1382/2021

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

BRAYAN SILVA GENELHUD, GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA e MATHEUS FELICIANO RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2.º, inc. II, c.c. § 2.º-A, inc. I e art. 158, § 1.º e 3.º, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal, porque no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 18:30 horas, na Rua Mozart, altura do número 177, Bairro Jardim Casa Grande, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, esta exercida com emprego de arma de fogo, contra David Alexandre Pardi, documentos pessoais, cartão bancário e um aparelho de telefone celular da marca Samsung, pertencentes à vítima.

Consta ainda da denúncia, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima informados, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, constrangeram David Alexandre Pardi, mediante violência e grave ameaça, esta última exercida com o emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para si ou para

outrem, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, consistente em obrigar o ofendido a entregar seus cartões bancários e informar suas respectivas senhas, sendo que o crime foi cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição era necessária para a obtenção da referida vantagem econômica.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados (fls. 110). O M.P manifestou-se favoravelmente à representação (fls. 115/116). A prisão preventiva dos réus foi decretada aos 09.12.21, por decisão de fls. 125/126. Os mandados de prisão foram cumpridos, sendo o réu Matheus preso em 17.12.21 (fls. 142), o acusado Gustavo em 20.12.21 (fls. 153) e o réu Brayan em 25.12.21 (fls. 190).

Recebida a denúncia em 09.12.21 (fls. 125/126), os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 254/255). Na instrução criminal foram ouvidas a vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante, sendo os réus interrogados.

Após a fase do art. 402 do CPP, a Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação de regime fechado.

O Dr. Defensor Público, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, em caso de condenação, que seja reconhecido apenas o delito de extorsão pelo aplicação do princípio da consunção ou crime continuado, a aplicação do art. 387, § 2.º, do CPP e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O réu Brayan não foi ouvido na fase policial. Em juízo, negou ter praticado os crimes, alegando que não se recorda o que fazia na data dos fatos. Teve passagem com Gustavo quando menor. Trabalhava com higienização de estofados. Conhece o réu Gustavo desde a infância em 2017, mas se mudou de perto de sua casa e nem tinha mais contato. Tinha foto deles na delegacia, as quais estavam no Facebook, mas eram de quando era menor de idade (2018). Tem condenação por roubo. Conhece os policiais, em razão de diligências, prisões e por fazerem acerto, pois mora em viela de tráfico. A sua avó falou que foram os policiais e como não estava foram embora. Então, contratou advogado e este que disse que queriam dinheiro para não jogar B.O nele. Mandaram intimação e por isso não compareceu.

Mateus (réu) permaneceu calado na fase policial (fls. 38). Em juízo, negou ter praticado os crimes e informou que nesse dia estava em Minas Gerais. Narrou que não voltou para a cadeia, por estar ameaçado pelos policiais e foi incriminado. Informou que acabou sendo detido por não ter voltado para a cadeia e foi chamado para reconhecimento. Não conhecia os corréus. Tem condenação por um roubo. Trabalhava como autônomo vendendo pão de queijo na rua. Não conhece a vítima, nem os policiais. Foi de ônibus para Minas Gerais, mas não tem a passagem para comprovar.

O acusado Gustavo, ouvido na fase extrajudicial (fls. 46), negou a prática dos crimes, dizendo que não participou de nenhum roubo. Disse que esteve preso durante 06 anos, por tráfico de drogas, e que depois de solto não praticou nenhum crime. Afirmou, após ver fotografias, que conhecia os acusados Brayan e Mateus, pois eram seus amigos de infância. Declarou que reconhecia como sendo dele a fotografia juntada nos autos, em que estava em cima de uma motocicleta, postada nas redes sociais com o nome de "Gustavo Edward" (fls. 25). Informou que no ano de 2017 foi apreendido (era menor) juntamente com o acusado Brayan, pelo roubo de um celular. Posteriormente, interrogado formalmente, permaneceu calado (fls. 88).

Em juízo (Gustavo), negou ter praticado os crimes. Foi condenado por tráfico, não estava morando mais na Casa Grande e ficou longe do réu Brian (amigo de infância). Não lembra onde estava na data dos crimes. Disse que não conhece o réu Mateus. Trabalhava revendendo máquinas no Facebook. Tem condenação por tráfico. O policial Cleber e outros fazem acertos nas biqueiras. Conhece de vista o Escrivão. Na rede social tem o nome de Gustavo Edward.

A vítima, na fase extrajudicial (fls. 06), relatou que no dia 24.08.21 interessou-

se por uma motocicleta (Honda Fan, cor preta, ano 2015, placas não visualizáveis) anunciada no Facebook pelo valor de R\$ 3.200,00, que segundo o anunciante, tinha débitos pendentes. Disse que entrou em contato com o suposto anunciante por meio do Messenger do Facebook, quando solicitou o número daquele no WhatsApp. Esclareceu que não possuía o referido número em razão do posterior roubo de seu celular. Declarou que o suposto anunciante da motocicleta informou que ele poderia verificar as condições da motocicleta na Rua Mozart, n.º 177, Bairro Casa Grande, neste município. Narrou que se dirigiu até o endereço e neste viu uma motocicleta com as mesmas características da moto anunciada, em uma garagem escura, onde estava uma mulher de cor morena, manuseando um celular. Falou que perguntou à mulher se a moto estava à venda, ela disse que não sabia e digitou algo no celular. Afirmou que logo em seguida surgiram três homens no local, todos portando arma de fogo, um dos quais o abordou, anunciou o roubo e mencionou a motocicleta anunciada no Facebook. Disse que os homens roubaram seu celular e cartão de crédito Itaú/Mastercard e o obrigaram a fornecer a senha deste cartão. Relatou que permaneceu sob vigilância de dois dos homens, por cerca de meia hora, e sob a mira de arma de fogo. Informou que seu cartão de crédito foi utilizado por duas vezes, em uma adega de nome Zuza Distribuidora de Bebidas, nesta cidade, pelo que teve um prejuízo R\$ 3.000,00, e que foi obrigado ainda a digitar a senha de seu PIX no aplicativo Caixa Tem, referente ao saldo de R\$ 242,00 que possuía em uma conta corrente na Caixa Econômica Federal (cujos dados não sabia informar).

Ouvida novamente na fase policial (fls. 10/11), a vítima disse que viu o anúncio de venda de uma motocicleta CG 150 de cor preta na rede social Facebook, entrou em contato com o suposto vendedor e este informou que poderia ver a motocicleta na Rua Mozart, n.º 177, Jardim Casa Grande. Relatou que foi até o endereço informado e viu a motocicleta, porém, foi atendido por uma mulher branca de cabelos avermelhados, que lhe disse que não estava à venda. Afirmou que a mulher estava com um celular digitou algo no aparelho quando o viu, logo em seguida três homens saíram de um "escadão" existente no local, um deles estava armado e o abordou, roubando seus pertences. Informou que posteriormente reconheceu este homem nas redes sociais, onde se identificava como "Henry Gabriel". Relatou que em seguida foi rendido por outro dos três homens, que ficou apontando uma arma para seu rosto o tempo todo e debochando, e que o terceiro homem fazia a segurança do grupo. Declarou que permaneceu com os criminosos por cerca de trinta minutos, depois foi solto e eles se evadiram. Informou que ativou sua conta no Facebook em outro celular, apareceu em sua rede social o perfil de "Ya Edward", quando, por meio de amigos, conseguiu identificar tal pessoa como "Henry Gabriel". Na delegacia, descobriu que os acusados utilizavam nomes falsos nas redes sociais, pois em pesquisas foi verificado que "Gustavo Edward" e "Ya Edward" se referiam ao réu Gustavo da Silva Oliveira, e que "Henry Gabriel" era, na verdade, o acusado Brayan Silva Genelhud. Narrou que através de reconhecimento fotográfico identificou o terceiro autor como o acusado Matheus Feliciano Rodrigues. Afirmou que enquanto esteve sob o poder dos acusados, o réu Brayan deixou do local na posse de seu cartão e senha e efetuou as compras no valor de R\$ 3.000,00, em uma adega, e uma transferência de R\$ 240,00 via PIX. Disse que permaneceu sob vigilância dos acusados Gustavo e Matheus, que estavam armados, enquanto Brayan realizava as transações com seu cartão subtraído. Relatou que quando Brayan retornou, este informou aos demais que havia conseguido passar o cartão e mandou que o libertassem. Reconheceu os acusados identificados na delegacia como os autores do roubo, pois estes estavam com os rostos totalmente expostos durante a ação (auto de reconhecimento e fotografias de fls. 20/25, 26/31, 32/36 e 37). Comprometeu-se a apresentar o recibo da transferência PIX efetuada em sua conta para uma terceira pessoa.

Em juízo, narrou que viu o anúncio de uma moto no Facebook e se interessou, informaram o endereço e foi até o local. Havia uma moça que disse que a venda da moto não era lá e fechou a porta. Nesse momento, foi abordado por três homens armados, dizendo que era para dar o celular e que se não desse a senha iam matá-lo. Ficou no mato com dois assaltantes e um saiu com seu cartão de crédito e efetuou compras (R\$3.000,00, uma compra de R\$1.000,00 e outra de R\$2.000,00 em bebidas) fizeram pix do seu celular (230,00). Narrou que dois ficaram com ele no mato e

outro foi fazer compras com seu cartão. Não recuperou o dinheiro. Ficou em torno de quarenta minutos em poder dos assaltantes. Narrou que pediram amizade no "Facebook, identificou como um dos autores do crime e os demais, foi na delegacia e mostrou as fotos deles. Na delegacia reconheceu os três réus pessoalmente. O assaltante moreno de bigode disse que se não tivesse dinheiro ia morrer. Reconheceu nesta audiência os réus: n.º 5- acusado Braian (foi o primeiro que o abordou e pegou seu cartão e saiu para fazer compras), n.º 3- acusado Gustavo (pegou seu celular, tirou "barato" dele, foi ameaçador e colocou a arma na sua cabeça) e n.º 1- réu Matheus (ficou na segurança). Havia iluminação na rodovia.

O policial Cléber, no relatório de investigações de fls. 14/19, informou que a vítima relatou no distrito policial o "modus operandi" dos crimes de roubo e extorsão ocorrida em 26.08.21, quando teve o celular e o cartão de crédito roubados, sendo este utilizado em uma adega, além de transferência bancária via PIX feita por eles em sua conta. Relatou que a vítima informou que demorou alguns dias para adquirir um novo celular, período durante o qual não utilizou as redes sociais, mas que foi informado por amigos de que seu status no Facebook permaneceu ativo, como se estivesse acessando a rede. Narrou que a vítima informou que assim que adquiriu um novo celular e acessou o Facebook, foi surpreendido por uma "sugestão de amizade" em seu perfil, relacionada ao perfil de um homem chamado "Gustavo Edward". Disse que vítima observou atentamente a fotografia de "Gustavo Edward" (fls. 14/15) e o reconheceu como um dos autores do roubo. Afirmou que o autor Gustavo, provavelmente, havia acessado a própria rede social ainda "logado" na conta da vítima, de forma que o algoritmo do Facebook entendeu que poderiam ser pessoas conhecidas e sugeriu um convite de amizade. Declarou que a vítima passou a analisar foto de amigos de "Gustavo Edward" até que entre eles veio a reconhecer um homem que se apresentava como "Henry Gabriel" (fls. 16/17), como outros dos três autores do roubo/extorsão. Disse que diante das informações da vítima, passou a tentar qualificar os autores e mediante pesquisas logrou identificar "Gustavo Edward" como sendo Gustavo da Silva Oliveira e "Henry Gabriel" como sendo Brayan Silva Genelhud. Informou que possuía a informação que ambos os acusados estariam praticando roubos na companhia de um terceiro homem, Matheus Feliciano Rodrigues, cuja fotografia foi apresentada à vítima, que o reconheceu como o terceiro autor do roubo. Informou que Matheus estava preso no CDP local, em razão de mandado de prisão cumprido em 06.09.21, referente a condenação por roubo. Falou que a vítima foi conduzida ao CDP de Diadema e efetuou reconhecimento pessoal de Matheus. Relatou, por fim, que em diligências à Caixa Econômica Federal, obteve um extrato com a informação da pessoa que recebeu a transferência PIX dos assaltantes, a qual foi identificada como Márcio Aparecido da Lima.

Os investigadores de polícia Luciano, Ricardo e Marcos, no relatório de fls. 106/111, esclareceram que em cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da medida cautelar n.º 1502921-25.2021.8.26.0161 (a autoridade policial havia representado pela prisão temporária e busca e apreensão nas residências de Gustavo e Brayan, mas foi deferido apenas este último pedido), não localizaram objetos relacionados aos crimes em comento, e os acusados não foram encontrados nos locais. Então, deixaram notificações para que fossem na delegacia. Disseram que o acusado Gustavo compareceu no distrito policial e negou ter praticado os crimes, falando que havia deixado a prisão há cerca de seis meses e não tinha cometido mais delitos e informou que conhecia os réus Brayan e Mateus, sendo que já havia sido apreendido com o primeiro por roubo. Informaram que a vítima reconheceu pessoalmente o acusado Gustavo como o homem que a abordou com arma de fogo e que a vigiou enquanto Brayan efetuava transações financeiras com seu cartão bancário roubado. Informaram que o acusado Brayan não compareceu na delegacia e que foi constatado que este possuía diversos antecedentes criminais e, em sua casa, havia uma escada previamente posicionada para auxiliar na fuga em caso de aproximação policial. Relataram que identificaram o recebedor do PIX efetuado pela vítima a mando dos autores, como sendo Márcio Aparecido de Lima, e que realizaram diversas tentativas de intimação a ele, que segundo informes obtidos, era morador de rua e usuário de drogas, pelo que não foi localizado. Falaram que intimaram Marcos Vinicius Ferreira Santana, que em pesquisas constava como

proprietário da Adega Zuza Distribuidora de Bebidas, onde os acusados efetuaram compras com o cartão da vítima, o qual informou na delegacia que não possuía qualquer maquininha de cartão de crédito em seu nome e que não possuía relação com os fatos em apuração (fls. 50/52). Disseram que diligenciaram na adega e identificaram o proprietário como sendo Jefferson Guimarães Tomaz dos Santos, que posteriormente compareceu na delegacia com os funcionários Fábio Soares e Maria José de Araújo Moura. Relataram que Jefferson prestou versão "fantasiosa" e declarou que a máquina utilizava para passar o cartão é de sua propriedade, porém, não se recordava da pessoa que o passou, bem como não apresentou extrato da máquina de cartão, apesar de solicitado (fls. 74/75). Afirmaram que Fábio e Maria José declararam que Jefferson costumava trocar cartões por dinheiro e era o único responsável por fazer as trocas (fls. 77/78 e 79/80). Informaram que identificaram e ouviram as testemunhas Lucas Mendes da Conceição e Matheus Nascimento Santos, residentes no imóvel próximo ao local dos fatos, os quais disseram que haviam percebido o crime em andamento, mas não tinham condições de reconhecer os autores (fls. 96/98 e 99/100). Esclareceram que a conduta de Jefferson Guimarães Tomaz dos Santos seria apurada em outro inquérito policial.

Luciano (Delegado de Polícia), em juízo, narrou que a vítima foi chamada para dar detalhes do crime e disse que recebeu solicitação de amizade de um deles. Diante disso, com as fotos apresentadas pela vítima (com outros nomes), como já conheciam as fisionomias, identificaram os réus Brian e Gustavo que já tinham informação na delegacia que estariam praticando roubos junto com o acusado Mateus. A vítima reconheceu os três réus por fotos. A vítima reconheceu Mateus pessoalmente. Não presenciou os reconhecimentos, porque não presidiu o ato, mas ficou sabendo que ocorreu pelas fotos das redes sociais e não por álbum da delegacia.

Ricardo (investigador), em juízo, falou que secretariou o ato, a vítima foi ver uma moto anunciada no Facebook, apareceram os três réus armados e a abordaram. No Facebook a vítima recebeu solicitação de amizade e através deste identificou o autor do crime. A investigação, diante de informações recebidas na delegacia, já sabia Gustavo, Brian e Mateus cometiam roubos juntos. Na busca e apreensão na casa, a avó do réu Brain falou que este estava no quarto, mas quando chegaram o mesmo já tinha se evadido (havia uma escada) e não compareceu na delegacia. Os réus Gustavo e Mateus foram reconhecidos pessoalmente pela vítima na delegacia e quanto ao acusado Brain não foi localizado.

Marcos (investigador), em juízo, narrou que, conforme investigação, a vítima se interessou por uma moto anunciada na rede social, foi até a residência indicada, sendo rendida com arma e a levaram para um "escadão". Informou que um deles saiu com o cartão da vítima. Os demais ficaram com a vítima. O BRAYAN GENELHUD é sempre o mentor dos crimes e de alta periculosidade. O Escrivão informou que a vítima passou as informações dos autores do crime que conseguiu nas redes sociais. Informou que através das redes sociais identificaram os autores do crime como sendo os réus que usavam nomes alterados.

O fato de as testemunhas serem policiais não as torna impedidas ou suspeitas (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

As negativas judiciais dos réus estão isoladas nos autos, posto que sequer conseguiram demonstrar onde estavam no momento dos crimes. Além disso, os acusados são reincidentes por roubo, o que torna ainda mais frágeis as suas negativas. A vítima reconheceu os três réus em juízo com certeza (n.º 1- réu Mateus, n.º 03- réu Gustavo e n.º 05 réu Brain), identificando a conduta de cada um deles. Observo

que foram colocadas cinco pessoas e que reconheceu apenas os réus. A vítima não conhecia os réus pelo que não teria motivos para incriminá-los indevidamente. Assim, considerando que os acusados foram reconhecidos pela vítima na fase extrajudicial e em juízo e os depoimentos dos policiais, é caso de condenação. A qualificadora de emprego de arma de fogo está provada pelas declarações da vítima, sendo irrelevante que a arma não foi apreendida. No sentido de que a qualificadora pode ser demonstrada por outros meios de prova, bem como que se o acusado alegar a ausência de potencial lesivo da arma será dele o ônus da prova nos termos do art. 156 do CPP e que se a arma não tem o poder de disparar serve como instrumento contundente apto a produzir lesões graves: STF- HC 93.353-0, Rel. Ricardo Lewandowski, j. 04.11.08).

O concurso de agentes também está demonstrado, uma vez que a prova produzida é no sentido de que o réu Brayan abordou a vítima, armado, anunciou o roubo e subtraiu o celular e o cartão dela, enquanto os acusados lhe davam guarida e intimidavam a vítima, pelo que houve divisão de tarefas.

Quanto ao crime do art. 158 também está demonstrado, e que se deu na modalidade denominada "sequestro relâmpago", pois cometido mediante restrição da liberdade da vítima, que permaneceu vigiada pelos acusados Gustavo e Mateus enquanto o outro réu efetuava compras e transação bancária via PIX com o cartão roubado dela. Os acusados obtiveram a indevida vantagem, posto que as transações bancárias foram realizadas, conforme documentos juntados às fls. 13 (recibo PIX) e 60/62 (fatura do cartão de crédito da vítima, informando as compras realizadas pelos réus no estabelecimento "Chama Bar"). Incide o concurso de agentes, posto que praticado o crime pelos mediante divisão de tarefas, como já exposto.

Não há que se cogitar de crime único em razão do princípio da consunção, nem de crime continuado, uma vez que os crimes foram praticados mediante duas condutas decorrentes de desígnios autônomos, ou seja, inicialmente os réus abordaram a vítima para roubá-la, quando subtraíram seu celular e cartão. Em seguida, os acusados subjugaram a vítima, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (todos estavam armados) e a mantiveram no local, onde permaneceu com os acusados Gustavo e Mateus, enquanto Brayan saiu para utilizar o cartão de crédito roubado. Posteriormente, depois de já ter usado o cartão da vítima para benefício do grupo, o réu Brayan retornou ao local e a vítima foi libertada.

Nesse sentido:

"O juízo a quo condenou os réus pelo crime de extorsão mediante sequestro somente. Fundamentou que os demais delitos - roubo e extorsão - restaram absorvidos, visto que desde o início os réus anunciaram o "sequestro". Os criminosos, desde o início, já tinham desígnio único.

Entretanto, tal posicionamento não deve prevalecer. Os apelantes da defesa tiveram condutas autônomas devendo, portanto, caracterizar concurso material. Não há que cogitar a ocorrência de crime continuado, pois, apesar das condutas terem as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, não preenche o requisito de crime da mesma espécie, porque não localizados no mesmo tipo penal.

O princípio da consunção revela que determinadas condutas criminosas não devem ser consideradas singularmente, em razão destas serem meio necessário ou etapa normal de preparação ou execução de outro crime. Temos, então, o crime-fim absorvendo o crime-meio.

Entretanto, no caso em epígrafe, não pode ocorrer absorção como considerou o juízo "a quo". As condutas criminosas não constituem meio necessário para um fim determinado, mas sim desígnios autônomos.

Os apelantes da defesa não tinham a intenção de cometer só o roubo, pois não saíram do carro logo após terem conseguido o relógio e o dinheiro que estava na carteira.

Diante do contexto fático é nítido o propósito de perseguir vários tipos penais. A norma penal do roubo não é caminho necessário para se alcançar o tipo da extorsão nem o tipo da extorsão mediante sequestro.

Além disso, no segundo momento do "iter criminis", quando os réus exigem o cartão bancário e a senha e entregam a um terceiro elemento não identificado, há o crime de extorsão (hoje, com a Lei 11.923/09, seria o seqüestro relâmpago, artigo 158,

parágrafo terceiro, que não pode ser aplicado, pois os fatos ocorreram sob a égide de outra lei menos severa)" (Apelação nº 990.09.175971-6, 3.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. em 23.02.10).

"Não há que se falar em crime único ou concurso formal, ao invés de concurso material, como sentenciado, eis que as ações cometidas foram independentes e de desígnios autônomos, sendo ambas caracterizadas em momentos diversos da conduta criminosa.

Leia-se:

"É possível que o sujeito, depois de subtrair bens da vítima, force-a a uma conduta, como entregar um objeto ou emitir um cheque. Há dois crimes em concurso material (RTJ, 93:1077, 100:940 e 114:1027:RT, 539:392, 515:393, 568:384 e 688:355: RJTSP, 68:390; JTACrimSP, 69:271, 70:38, 45:233, 50:34, 76:449, 80:269 e 87:470; Entendimento uniforme da extinta Equipe de Repressão a Roubos do Ministério Público de São Paulo, nº 9" ("Código Penal Anotado", Damásio E. de Jesus, 19a edição, 2009, p. 608/609)" (Apelação n.º 990.09.243237-0 - SÃO PAULO, 5.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Marcos Zanuzzi, j. 11.03.10). Incide o concurso material, posto que os crimes foram praticados mediante ações distintas.

Ante o quanto exposto, impõe-se a condenação dos acusados, sendo que segundo consta dos autos são reincidentes (réu Gustavo - fls. 278 - proc. 1502469-22.2019 e fls. 277/278 - proc. 1502469-22.2019; réu Brayan - fls. 281/282 - proc. 14-61.2019; réu Mateus - fls. 285 - proc. 1500282-75.2018).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quanto ao crime de roubo, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Aumento a pena de 1/6 pela reincidência dos acusados.

Aumento as penas de 2/3, por estar presente a qualificadora dos § 2.º-A, inc. I, do art. 157 do Código Penal, observando que embora esteja configurada também a qualificadora de concurso de agentes, no concurso de causas de aumento prevalece a causa que mais aumente, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Finalizo as penas em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias- multa.

Em relação ao crime de extorsão, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base pelo crime do art. 158, § 3.º do CP, em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa. Aumento as penas de 1/6, em razão da reincidência dos acusados.

Aumento as penas de 1/3, por estar presente a causa de aumento prevista no § 1.º do art. 158 do CP, consistente no concurso de pessoas para prática da extorsão em razão da quantidade de agentes, ou seja, três.

Finalizo a pena pelo crime de extorsão qualificada em 9 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa.

As penas do roubo e da extorsão qualificados totalizam 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 32 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante do montante das penas (superior a 8 anos- art. 33, § 2.º, "a", do Código Penal) e por ser o único compatível com a gravidade das condutas em concreto, pois tratam-se de crimes de roubo e extorsão praticados com superioridade de agentes (os três réus) em relação à vítima que estava sozinha e foi ao local em razão do falso anúncio de venda de uma motocicleta, com emprego de ameaça de morte e restrição da liberdade da vítima, ou seja, em pouco tempo praticaram vários crimes, o que indica audácia e periculosidade dos agentes (art. 33, §3.º, do Código Penal). Quanto ao dia-multa será à razão mínima, em face da situação econômica dos acusados.

Ademais, os réus são reincidentes, e conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". Além disso, as circunstâncias não são favoráveis, pois são reincidentes específicos, por roubo (réu Gustavo - fls. 278 - proc. 1502469-22.2019 e fls. 277/278 - proc. 1502469-22.2019; réu Brayan - fls. 281/282 - proc. 14-61.2019; réu Mateus - fls. 285 - proc. 1500282-75.2018), o que denota personalidade voltada para crimes patrimoniais, pelo que não preenche os requisitos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a

pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”).

A jurisprudência é no sentido de que o roubo é crime que traz intranquilidade à sociedade e coloca em risco potencial a vida da vítima, pelo que deve ser imposto o regime fechado, ainda que primário e independentemente da pena aplicada, pois isso não demonstra menor periculosidade e decorre de item independente de fundamentação interpretativa dos arts. 33, § 2.º e 59 do Código Penal (Ap. Criminal

n.º1.120.965.3/1, 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 08.11.07, Rel. Pinheiro Franco; Ap. Criminal n.º 1.079.453.3/2, 5.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 08.11.07, Rel. Tristão Ribeiro; STJ, 6.ª T., H.C. n.º 18.819/SP, cf. RT 806/486).

“Inexiste ilegalidade na escolha do regime fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime – o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade da vítima e o concurso de agentes, com periculosidade e destemor exacerbados-, ainda que o agente seja primário e o quantum da pena – 5 anos e 8 meses de reclusão- seja inferior a oito anos (art. 33, §3.º, do CP). Habeas Corpus não conhecido”. (STJ, HC 282.211/SP, Rel. Ministro ROGERIO SHIETTI CRUZ, DJE 07.04.14).

“...o comando legal do art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto” (HC 295232/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6.ª Turma do STJ, DJE 09.03.15).

“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da reprimenda” (STJ- 6.ª Turma, HC 262.939/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 08.04.14, DJE 25.04.14).

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, “Lex specialis derogat generali” (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (os réus Brayan e Gustavo foram presos em 25.12.21 e 20.12.21, respectivamente, e o réu Mateus foi preso por este processo em 17.12.21, pelo que ainda não cumpriram 1/6 da pena fixada).

Por outro lado, “ad argumentandum”, ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO BRAYAN SILVA GENELHUD, GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA e MATHEUS FELICIANO RODRIGUES à pena de 17 (DEZESSETE) ANOS, 1 (HUM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, com início no REGIME FECHADO, e 32 (TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se acharem incursos no art. 157, § 2.º, inc. II, c.c. § 2.º-A, inc. I e art. 158, § 1.º e 3.º, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

Tendo em vista que os réus Brayan e Gustavo foram presos preventivamente (o réu Mateus já estava preso, por outro Juízo), bem como por ainda estarem presentes os requisitos da preventiva, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, posto nada há que o vincule ao distrito da culpa (os acusados Brayan e

Gustavo não comprovaram ocupação lícita nem residência fixa, e o réu Mateus está preso também por outro Juízo) e é incabível qualquer benefício, conforme decisão que decretou as prisões preventivas (fls. 126/127), recomendem-se na prisão em que se encontram.

Fixo o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da Lei n.º 11.719/08), em R\$ 3.240,00, referente à compra no valor de R\$ 3.000,00, realizada pelos réus no cartão de crédito da vítima (fls. 61), e à transferência via PIX no valor de R\$ 240,00, efetuada por elas na conta bancária dela (fls. 13); que constitui título executivo a ser cobrado no cível. Observo que não consta dos autos o valor de celular subtraído.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária conforme decisão nesta audiência (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados e providencie-se o cálculo das multas, abrindo-se vista às partes. Oportunamente, archive-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 28 de março de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA